

Consensualismo, eficiência e pluralismo administrativo: um estudo sobre a adoção da mediação pelo TCU

BRUNO DANTAS¹

Pós-Doutor em Direito (UERJ). Doutor e Mestre (PUC-SP). *Visiting Researcher Fellow* na *Benjamin N. Cardozo School of Law* (EUA), no *Max Planck Institute for Regulatory Procedural Law* (Luxemburgo) e na Universidade de Paris 1 *Panthéon-Sorbonne* (França). Professor de Direito (UERJ, UNINOVE e FGV Direito-Rio).

SUMÁRIO: 1 *Introdução* • 2 *Da atividade imperativa unilateral à cultura do diálogo: a metamorfose administrativa impulsionada pelo desenvolvimento da governança pública* • 3 *Fundamentos teóricos do consensualismo e a inserção da mediação na Administração Pública: promovendo eficiência e pluralismo administrativo* • 4 *Transação no Poder Público vs. Indisponibilidade do interesse público* • 5 *Sobre a implementação da mediação no Tribunal de Contas da União: fast-track para a homologação de reequilíbrios em contratos de infraestrutura* • 6 *Conclusão* • 7 *Referências*.

RESUMO: O artigo tem por objetivo demonstrar o aporte teórico necessário para a implementação de um centro de mediação no Tribunal de Contas da União. Busca-se demonstrar que a mediação é uma técnica que resulta de um amplo movimento de rompimento com o teor vertical que marca o direito administrativo clássico, sendo a sua utilização no setor público imprescindível para a concretização de uma série de objetivos e valores constitucionais. Para tanto, a pesquisa, que adota a técnica dedutiva, desenvolve-se pelo procedimento de revisão bibliográfica nacional e estrangeira, se dedicando, em um primeiro momento, a demonstrar as origens e o desenvolvimento da noção de Administração Pública Consensual para, no final, tecer considerações sobre a implementação de um centro de mediação no Tribunal de Contas da União, bem como sugerir o procedimento que poderia ser adotado para a condução das transações em processos objeto de controle pelo Tribunal.

PALAVRAS-CHAVE: Administração Pública Consensual • Mediação • Tribunal de Contas da União.

1 O autor expressa seu agradecimento à gentil acolhida recebida do *Institut de Recherche Juridique* da Universidade Paris 1 *Panthéon-Sorbonne*, em especial ao professor Loïc Cadiet, que o recebeu pessoalmente na Universidade no período em que realizava as pesquisas que deram origem a este trabalho. Agradece também a valiosa colaboração do advogado e especialista em direito processual civil, Caio Victor Ribeiro dos Santos, que dedicou sua inteligência e capacidade de pesquisa para fornecer importantes subsídios a este trabalho.

Consensualism, efficiency and administrative pluralism: a research on the implementation of a mediation center in the Federal Court of Accounts

CONTENTS: *1 Introduction • 2 From unilateral imperative activity to the dialogues culture: the administrative metamorphosis boosted by the public governance's development. • 3 Consensualism's theoretical foundations and the insertion of mediation of Public Administration: promoting efficiency and administrative pluralism • 4 Transaction in the Public Administration versus public interest Unavailability • 5 About the implementation of a mediation center in the Federal Court of Accounts: fast-track to the rebalance's homologation in contract's infrastructure • 6 Conclusion • 7 References.*

ABSTRACT: The article has the purpose of giving the theoretical contribution needed for the implementation of a mediation center at the Federal Court of Accounts. It seeks to demonstrate that mediation is a technique that results from a wide movement of rupture with the vertical content that traditionally marks the classic administrative law and that its use in the public sector is essential for the realization of several constitutional values and objectives. For this purpose, the research, which adopts the deductive technique, is developed by the national and foreign literature review procedure, seeking, at first, to dive into the origins and reasons for the development of the notion of Consensual Public Administration in order to make, at the end, considerations about the implementation of a mediation center in the Federal Court of Accounts, as well as to suggest the procedure that could be adopted for conducting transactions in proceedings subject to the Court's adjudication.

KEYWORDS: Consensual Public Administration • Mediation • Federal Court of Accounts.

Consensualismo, eficiencia y pluralismo administrativo: un estudio sobre la adopción de la mediación por TCU

CONTENIDO: 1 Introducción • 2 De la actividad imperativa unilateral a la cultura del diálogo: la metamorfosis administrativa impulsada por el desarrollo de la gobernanza pública • 3 Fundamentos teóricos del consensualismo y la inserción de la mediación en la Administración Pública: promoviendo eficiencia y pluralismo administrativo • 4 Transacción no Poder Público vs. Indisponibilidad del interés público • 5 Sobre la implementación de la mediación en el Tribunal Federal de Cuentas: fast-track para a homologación de reequilibrios en contratos de infraestructura • 6 Conclusión • 7 Referencias.

RESUMEN: El artículo tiene el propósito de dar la contribución teórica necesaria para la implementación de un centro de mediación en el Tribunal Federal de Cuentas. Busca demostrar que la mediación es una técnica que resulta de un amplio movimiento de ruptura con el contenido vertical que tradicionalmente marca el derecho administrativo clásico y que su uso en el sector público es esencial para la realización de varios valores y objetivos constitucionales. Para este propósito, la investigación, que adopta la técnica deductiva, es desarrollada por el procedimiento de revisión de literatura nacional y extranjera, buscando, en primer lugar, profundizar en las orígenes y razones para el desarrollo de la noción de Administración Pública Consensual para hacer, al final, consideraciones sobre la implementación de un centro de mediación en el Tribunal Federal de Cuentas, así como sugerir el procedimiento que podría adoptarse para realizar transacciones en procedimientos sujetos a la adjudicación del Tribunal.

PALABRAS CLAVE: Administración Pública Consensual • Mediación • Tribunal Federal de Cuentas de Brasil.

1 Introdução

Colhendo as lições que as transformações do direito no fim do século passado deixavam aos juristas dos mais diversos cantos do mundo, Roger Perrot, ao diagnosticar a situação vivenciada na França, anotava:

Neste fim de século XX, o jurisdicionado aspira a uma Justiça mais simples, menos solene, mais próxima de suas preocupações cotidianas, aquela que numa palavra se denomina 'Justiça de Proximidade'. (1998, p. 161-162).

Realmente, desde o fim do século passado, não só o Brasil, mas o sistema jurisdicional de inúmeros países embarcou em um movimento de redimensionamento de sua estrutura de resolução de conflitos que vem, com cada vez mais força, priorizando uma filosofia de desapego à rigidez procedimental e de rompimento com a verticalidade que há muito caracterizou a relação entre Estado-juiz e jurisdicionado (GAJARDONI, 2007).

Os ventos da *justiça da proximidade* foram tão férteis que não se detiveram apenas sobre a estrutura judiciária e alcançaram também a Administração Pública, abalando dogmas que, por séculos, sua teoria geral manteve incólume.

É certo, como anota Jaques Chevallier (1993, p. 17), que o êxito do direito administrativo, a continuidade de suas teorias centrais, e inclusive a supremacia de que gozou por muito tempo em relação a outros ramos do direito, se deve à estabilidade de seu tecido conceitual, elaborado com notável coesão e coerência pelo coro de duas vozes – doutrina francesa e Conselho de Estado –, o que acabou fazendo dele um núcleo duro e quase inabalável do direito público capaz de opor resistência às históricas intempéries políticas e econômicas que costumam dismantelar as leis.

No entanto, os dilemas próprios do século XXI também têm sua força e foram capazes de provocar a revisão de alguns aspectos desse núcleo conceitual, permitindo o florescer de novas fórmulas e ideias. Uma delas é a transação no Poder Público, que atinge antigas certezas acerca da supremacia e da indisponibilidade do interesse público.

Neste trabalho o que se busca é demonstrar o aporte teórico necessário para a implementação de um centro de mediação no Tribunal de Contas da União (TCU). Para tanto, servimo-nos de pesquisa bibliográfica e documental, tanto nacional quanto estrangeira, realizando, sobretudo, um cotejo entre a doutrina francesa e a brasileira acerca do tema.

Com a finalidade de cumprir a tarefa a que nos propomos, dividimos o trabalho em quatro etapas: uma primeira, destinada a abordar a origem e as razões que levaram ao desenvolvimento, na França, das ideias responsáveis pelo rompimento com a verticalidade característica do direito administrativo clássico; uma segunda, na qual passamos a demonstrar como esse fenômeno foi recepcionado no Brasil e a sua importância para a realização da eficiência e do pluralismo administrativo; uma terceira, na qual são feitas reflexões acerca da compatibilidade do consensualismo com o princípio da indisponibilidade do interesse público; e, por fim, uma quarta, que se destina a demonstrar a utilidade e importância de se implementar um centro de mediação no Tribunal de Contas da União, oportunidade em que é sugerido o procedimento que poderia ser adotado para a condução das transações.

2 Da atividade imperativa unilateral à cultura do diálogo: a metamorfose administrativa impulsionada pelo desenvolvimento da governança pública

O final do século passado foi responsável por demarcar o início de uma grande mudança na arquitetura do Estado contemporâneo. Nesse contexto de transformação, credita-se certa proeminência à França pelo desenvolvimento das bases do modelo de Administração que passou a ser adotado em inúmeros países². E isso com muita razão: foi ali que uma das mais importantes ideias de gestão do setor privado teria sido aperfeiçoada e adaptada à Administração Pública: a Governança Pública (*Gouvernance publique*).

A ideia de governança, que vinha sendo trabalhada na Escola de Chicago por estudiosos como Ronald Coase, encontrou na França terreno fértil. Isso se deve ao fato de que a estrutura administrativa daquele país, na segunda metade do século passado, já conhecia os problemas da burocracia pública que o Brasil iria criticar fortemente na virada do século.

A inefetividade era um problema que precisava ser combatido, e, embora houvesse certo ceticismo por parte dos legalistas na superação dessa crise pelo uso de ferramentas da análise econômica, uma série de estudos favoreceu o movimento (CAILLOSSE, 2003, p. 122).

2 A administração da Justiça, é importante destacar, foi tanto influenciada pela ideologia gerencial (*gouvernance*) que emergiu na França na segunda metade do século passado, e amplamente difundida pela doutrina administrativa (CADIET, 2008, p. 133-150), como pelos notáveis trabalhos da Comissão Florença, capitaneada por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, esses bastante difundidos no Brasil pela doutrina processual (CAPPELLETTI; GARTH, 1988).

Em uma mesma solução foram colocadas teorias das ciências econômicas e da gestão pública e estas foram aplicadas ao contexto jurídico francês, no que Chevallier (1993, p. 30) chamou de “encontro da crítica gerencial com os desafios liberais no direito administrativo”. A crítica gerencial parte da premissa de que haveria uma contradição entre o direito administrativo e o princípio da eficiência, visto que o direito administrativo constituiria uma “estrutura rígida, uma camisa de força real, que é um obstáculo à ação, um obstáculo à mudança”, não havendo que se falar em eficiência sem que houvesse um afrouxamento das restrições que esse direito impunha.

Sobre esse ponto, arremata Chevallier:

A extensão gradual à Administração de uma racionalidade do tipo gerencial, onde a eficiência tem precedência sobre todas as outras considerações, leva ao questionamento da racionalidade jurídica sobre a qual aquela foi construída: a gestão pressupõe uma ruptura radical com os pressupostos que fundaram o modelo clássico de Administração. (1993, p. 30).

O protesto neoliberal, por sua vez, se resigna contra o fato de que o direito administrativo seja, em essência, “um direito de desigualdade e privilégio: marcado irreversivelmente com o selo da unilateralidade, seria o instrumento para a administração da sociedade pelo Estado; esse modelo estatal de regulação social, a herança de uma “cultura política ultrapassada”, seria obsoleta”. (CHEVALLIER, 1993, p. 32; tradução nossa).

É nesse contexto que direito e gestão, assevera Caillosse (2003, p. 123), começam a trabalhar em interação em favor da mesma causa.

A partir dali, a ideia de governança pública se torna um poderoso mecanismo de reforma. Levando na frente o estandarte da modernidade e da eficiência, inspira a crença na necessidade de se promover, em todos os níveis e em organizações sociais de todos os tipos, novos métodos de tomada de decisão e de ação. Confluíam para esse novo olhar outras fórmulas que mostravam êxito na experiência internacional: a Governança Corporativa (*Corporate Governance*), da qual se extraíam princípios modernos de interação entre acionistas e diretores; a Boa Administração (*Good Governance*), pela qual se introduziam diretivas de reforma propostas pelas instituições financeiras internacionais para os países em desenvolvimento; e a Governança Global (*Global Governance*), que definia novos modos de regulação e integração com a sociedade internacional (CHEVALLIER, 2003, p. 203-217).

Apesar da diversidade, todas essas iniciativas são conjugadas entre si, traduzindo, como anota Chevallier (2003, p. 206), uma verdadeira ideologia gerencial que se pautou, entre outras, nas seguintes diretrizes: (i) resolução de conflitos e erradicação de antagonismos irreduzíveis; (ii) rompimento com a lógica do poder, pois as escolhas coletivas passam a não ser mais uma questão só de política, mas de técnica; (iii) mitigação da supremacia unilateral do Estado, que seria apenas mais um ator entre tantos outros envolvidos e capazes de tomar parte nas soluções; e (iv) a possibilidade de acordar certas regras do jogo.

Com efeito, a perspectiva gerencial da governança pública propõe um afastamento da noção hobbesiana e tradicional de Estado (VILLEY, 2005, p. 713), cuja concepção de poder se vê marcada pelo selo da assimetria, desigualdade e unilateralidade. O próprio termo *governança*, ao invés de *governo* ou *política*, foi empregado pelos franceses para que não se lhe fossem atribuídas as conotações negativas que há muito se associa aos últimos (CHEVALLIER, 2003, p. 204).

As técnicas de gestão caracterizadas pela imposição unilateral da dominação, e agasalhadas sob a vagueza do *interesse público*, já não correspondiam mais à forma como as sociedades contemporâneas mantêm o seu equilíbrio. Com a globalização, o mundo assiste à descentralização e à fragmentação do poder, naquilo que Manuel Castells (2002, p. 427) sintetiza sob a lógica difusa da sociedade em rede, e reformar a estrutura administrativa estatal sem pretender modificar a ideologia subjacente, sem compatibilizar o exercício do poder à sua própria realidade difusa de hoje, seria desrespeitar a clássica lição weberiana acerca da legitimação do poder: para que este se transforme em autoridade é indispensável contar com a adesão daqueles sobre os quais recairá (WEBER, 1979, p. 124-141).

Rompendo com esses paradigmas, que por todos os lados eram atingidos e percebidos obsoletos, a governança pública endereça duas importantes inflexões.

Por um lado, toma-se consciência de que o Estado não atua mais isoladamente na sociedade. O Estado não é o único a bordo, tampouco o único capaz de propor as melhores soluções. Não governa sozinho e não deve prestigiar seu interesse institucional em detrimento do interesse da população. Múltiplos são os atores envolvidos nos processos de tomada de decisão. Nessa conjuntura, a governança implica em um deslocamento das linhas divisórias que separavam o direito público do privado, e também entre as diferentes esferas de atuação (internacional, regional,

nacional e local). Caem os muros legais por trás dos quais a administração tradicional poderia afirmar suas diferenças (CAILLOSSE, 2003, p. 127)³.

Por outro lado, dessa nova lógica gerencial decorre que as soluções consensuais serão sistematicamente preferidas às fórmulas unilaterais: as escolhas devem ser resultado de negociações e compromissos, levando em consideração os pontos de vistas das partes envolvidas. O Estado aceita discutir em pé de igualdade com os demais atores no âmbito das decisões coletivas. Como assevera Caillosse (2003, p. 127), a *ação contratual* (grifos nossos) se torna uma das mais marcantes características dessa modernização institucional, constituindo-se como um verdadeiro princípio de regulamentação administrativa.

A governança pública é, portanto, uma abordagem plural e interativa de ação coletiva. Significa, em síntese, que nenhum ator pode controlar sozinho os processos de tomada de decisão, nem mesmo o Estado. Tendo em vista a complexidade dos problemas e a existência de múltiplos poderes, múltiplos atores, trata-se de coordenar sua ação e obter sua cooperação, reduzindo a unilateralidade para estimular a cultura do diálogo.

Philip Schmitter, citado por Jacques Chevallier, fornece um conceito preciso para a expressão:

Governança é um método ou mecanismo para regular uma ampla gama de problemas ou conflitos, pelos quais os atores chegam regularmente a decisões mutuamente satisfatórias ou vinculativas, por meio de negociação e cooperação”, sendo caracterizada por “formas horizontais de interação” entre atores que têm interesses contraditórios, mas que são suficientemente independentes um do outro que nenhum deles pode impor uma solução por si só, sendo suficientemente interdependente para que ‘todos eles’ percamos se nenhuma solução for encontrada. (SCHMITTER, 2000, p. 5 *apud* CHEVALLIER, 2003, p. 207; tradução nossa).

Como destaca Chevallier (2003, p. 207), a promoção de técnicas de governança pode realmente ser considerada ou como um sinal de um declínio irreversível na própria forma do Estado ou como marco de um ajuste nos modos de ação para um novo contexto social.

³ Do original francês: “Mais c’est surtout à l’intérieur même de ces dernières que la modernisation produit ses effets les plus visibles, en déplaçant les lignes du partage entre le droit privé et le droit public. S’employant à repenser l’action publique du point de vue de l’économie de marché où elle s’inscrit, elle l’incite ou, le cas échéant, l’oblige à emprunter les voies du droit commun. C’est ainsi que les vieilles barrières juridiques à l’abri desquelles l’administration classique avait pu affirmer ses différences et se soustraire à l’application du droit de la concurrence sont en train de craquer les unes après les autres”.

Deveras, o desafio atual não é tanto o de justificar um modelo de Estado cooperativo e horizontal, mas o de criá-lo. Não se trata mais de uma questão filosófica, da qual por considerável tempo, e com razão, se ocuparam os franceses, mas de uma questão de efetivação.

É nesse cenário que se encontra o Brasil, cuja gestão administrativa vem abraçando o consensualismo, mais ciosa que está do equilíbrio necessário entre interesses dos particulares e interesse da coisa pública como forma de boa governança.

3 Fundamentos teóricos do consensualismo e a inserção da mediação na Administração Pública: promovendo eficiência e pluralismo administrativo

Dentro de um conjunto de mutações mais amplas e diversas que afetam as formas tradicionais do exercício de autoridade nas organizações do mundo atual, sobre as quais há farta literatura científica de inúmeros ramos da epistemologia, a ideia de governança pública foi responsável direta por parte considerável das sementes que levaram ao florescimento, no Brasil, da filosofia do consensualismo na Administração Pública.

A *Administração Pública Consensual* é resultado desse movimento de modernização da gestão administrativa que rompe com um esquema que se alicerçava na imperatividade unilateral dos atos administrativos para contemplar um modelo pautado no diálogo, negociação, cooperação e coordenação, que não deixa, por isso, de seguir a lógica da autoridade, mas passa a ser matizada, porém, pela lógica do consenso (DI SALVO, 2018, p. 36).

Como o direito processual civil clássico, o direito administrativo foi forjado sob as bases do liberalismo que regia o modelo estatal do século XIX. Naturalmente, a noção de imperatividade do Estado (cuja abstenção na economia em nada diminuía o teor vertical de seu poder) conformou os principais institutos e categorias do direito administrativo, resultando daí o tradicional comportamento estatal manifestado por meio de atos administrativos cujos atributos compreendem uma noção de autoridade que prestigia a unilateralidade e a assimetria entre Administração e administrados (OLIVEIRA; SCHWANKA, 2008, p. 38).

É em sentido diametralmente oposto a esse modelo que surge o consensualismo, por sua vez designando o “emprego em larga escala de métodos e técnicas negociais ou contratualizadas no campo das atividades perpetradas pelos órgãos e entidades públicas” (OLIVEIRA; SCHWANKA, 2008, p. 19). Imbuída de uma tônica semelhante àquela que vem sendo empregada no âmbito jurisdicional (GRINOVER; WATANABE; LAGRASTA NETO, 2008), a condução da ação pública por meio de técnicas consensuais

deve ser visualizada não como mera solução alternativa, como se decorresse apenas de uma necessidade circunstancial imperiosa, mas como uma *solução preferencial*, que opera a administração da justiça sob a dupla dimensão de uma *boa administração*: a dimensão econômica, para a eficiência, e a dimensão social, para a equidade (DI SALVO, 2018, p. 38).

A boa administração da justiça, destaca Di Salvo:

[...] não impõe um dever-ser que cede às pressões de resultados quantitativos, aliás, a boa administração da justiça concentra-se sobretudo nos meios de distribuição da justiça e na obtenção de resultado segundo um parâmetro de qualidade. (2018, p. 38-39).

Isso se traduz na reprovação à garantia de eficiência a qualquer custo, à revelia da participação do administrado, quando se mostra razoável inseri-lo no processo decisório: a aspiração não é só por resultados quantitativos, mas também qualitativos. Há que se buscar uma efetiva inclusão, tanto porque se lhe exige a democracia administrativa, quanto porque, se o poder, de fato, acha-se difuso em redes, a participação colaborativa no processo decisório clareia o caminho para que o titular da palavra final possa optar pela melhor (e, portanto, mais eficiente) solução.

É importante destacar que o conceito de democracia administrativa está relacionado ao de pluralismo administrativo. Compreende a percepção de que a legitimação democrática do exercício do poder estatal não se conforma tão só pela qualidade das leis e pela subordinação da atuação administrativa a elas. É necessário que concorra, para essa legitimação, a inclusão participativa do administrado. Destaca Di Salvo (2018, p. 27) que “a representatividade do administrado sobre a atuação administrativa é o que passa a dar nova tônica à democracia administrativa, que se vincula à democracia participativa”. Ideia semelhante foi incorporada ao direito processual civil através do conceito de contraditório participativo, que, por sua vez, confere às partes maior representatividade no curso do processo civil, devendo ser consideradas de forma efetiva e incluídas no processo de construção da decisão judicial (CARNEIRO, 2015, p. 58).

Por isso que a doutrina francesa vem aludindo à importância da contratualização da ação pública, que é uma decorrência direta da modernização institucional da Administração Pública. Jean-Pierre Gaudin (1999, p. 28-29 *apud* OLIVEIRA; SCHWANKA, 2008, p. 20), citado por Oliveira e Schwanka, aponta que na França esse fenômeno, que se imbrica com a descentralização, possui um enfoque de dupla

renovação: (i) formas de participação e consulta pública e (ii) formas de coordenação entre instituições e atores sociais que participam da ação pública.

Essa política de contratualização compreende uma série de procedimentos de ação pública que implicam em uma negociação explícita de objetivos, compromissos em projetos conjuntos e cooperação financeira dentro de um cronograma preciso entre atores públicos e privados, o que, em última análise, são menos obrigações legais do que compromissos políticos (GAUDIN, 2007, p. 20). Daí porque a expressão governar por contratos (*gouverner par contrat*), no Brasil recebida pela ideia de *Administração Consensual*, por sua vez, sinaliza a opção por uma forma de gestão administrativa que abdica da unilateralidade para valorizar o acordo, a negociação, a coordenação, a colaboração, a transação.

É nesse sentido a irretocável síntese feita por Odete Medauar (2003, p. 211):

A atividade de consenso-negociação entre Poder Público e particulares, mesmo informal, passa a assumir papel importante no processo de identificação de interesses públicos e privados, tutelados pela Administração. Esta não mais detém exclusividade no estabelecimento do interesse público; a discricionariedade se reduz, atenua-se a prática de imposição unilateral e autoritária de decisões. A Administração volta-se para a coletividade, passando a conhecer melhor os problemas e aspirações da sociedade. A Administração passa a ter a atividade de mediação para dirimir e compor conflitos de interesse entre várias partes ou entre estas e a Administração. Daí decorre um novo modo de agir, não mais centrado sobre o ato como instrumento exclusivo de definição e atendimento do interesse público, mas como atividade aberta à colaboração dos indivíduos. Passa a ter relevo o momento do consenso e da participação.

Toda essa conjuntura é que viabiliza a mediação como método de resolução de controvérsias na Administração Pública. Resultado da propagação do ideal democrático para além das fronteiras do campo político, a mediação tem por principal função compor conflitos e concertar interesses estatais e privados, incluindo o administrado no processo de *densificação do interesse público*, que não é monopólio estatal. O interesse público não se confunde com o mero interesse da Administração. Já faz algum tempo, assevera Dallari (2002, p. 16), que “o particular está deixando de ser considerado um adversário da Administração Pública, para transformar-se em agente de realização de interesses públicos”.

A mediação é, portanto, ferramenta adequada para concretizar a eficiência administrativa, seja porque cria uma via menos onerosa, mais célere e mais versátil para a composição do conflito ou para a administração dos interesses, seja

porque concorre para a legitimação do processo decisório mediante a promoção do pluralismo administrativo, revelando-se, assim, imprescindível para dar concretude ao consensualismo.

Antes, porém, de discorrer sobre a implementação da mediação no TCU, convém tecer considerações sobre a compatibilidade da transação com a Administração Pública.

4 Transação no Poder Público vs. Indisponibilidade do interesse público

Ao escrever sobre os desafios da modernização da gestão pública na França, após a década de 1960, Jacques Chevallier (1993, p. 17) anotou que o principal obstáculo à implementação de um modelo eficiente naquele país consistia no próprio direito administrativo, que constituía uma “estrutura rígida, uma camisa de força real, que é um obstáculo à ação, um obstáculo à mudança”. Isso se devia à própria base dogmática do direito administrativo, que aliava a imperatividade e a indisponibilidade como marcas indeléveis da atuação do Estado. Daí porque arremata o professor: “a gestão pressupõe uma ruptura radical com os pressupostos que fundaram o modelo clássico de Administração”⁴.

De fato, embora há quase duas décadas já se escreva sobre o tema no Brasil, só mais recentemente é que se nota um engajamento mais frutífero pela Administração na implementação de técnicas consensuais. Isso porque, entre outros fatores, pelo menos em um primeiro momento, uma parcela mais cética de estudiosos resistiu apontando que a transação seria incompatível com o princípio da indisponibilidade do interesse público, não estando o gestor autorizado a dispor acerca de um interesse que não lhe pertenceria.

Isso é uma meia-verdade. De fato, tem razão a crítica quanto à impossibilidade de o gestor, em seu próprio interesse, vir a dispor sobre o interesse público. Óbice também não há quanto à transação pelo poder público quando o interesse nela corresponde ao interesse institucional da Administração positivado em lei (v.g., acordo em sede judicial firmado pela Procuradoria de um Município). Situação diversa, porém, é a da transação quando inexistente essa autorização legal. Poderia, nesse caso, o gestor transigir?

⁴ Do original francês: “Plus le genre, la continuité du droit administratif se manifeste par la stabilisation de son cadre conceptuel: forgées de manière progressive, par le choeur à deux voix de la jurisprudence et de la doctrine, les grandes notions sur il il reste se sont amalgamées les unes aux autres, en formant un tissu conceptuel remarquablement cohérent et homogène; et ce tissu a résisté aux transformations pourtant trois partisans qui ont affecté la place de l’administration dans la société. Tous ces traits expliquent que la suprématie du droit administratif sur le droit constitutionnel n’ait pas été réellement contestée”.

Não assiste razão à resposta negativa geral a essa questão, uma vez que, ao invocar o princípio da indisponibilidade do interesse público como óbice à transação, o intérprete faz uma leitura desatualizada e assistemática do conjunto de normas que regem, atualmente, o direito administrativo: desconsidera que o interesse público é bem mais amplo que o mero interesse da Administração ou da Fazenda Pública, bem como que o princípio da eficiência pode admitir a transação em preferência à solução unilateral.

A perquirição do conteúdo do interesse público nos leva à clássica definição de Celso Antônio Bandeira de Melo (2009), formulada a partir das lições colhidas na obra de Alessi, que o divide em interesse público primário e secundário, identificando-se o primeiro com o interesse social, o interesse da sociedade ou da comunidade, e o último com o interesse tão só do aparelho estatal como uma entidade personalizada.

O interesse público a ser confrontado pela hipótese não pode ignorar a dupla acepção de sua natureza. Sendo assim, a indisponibilidade do interesse público não pode vedar a renúncia a determinadas posições jurídicas, nem o reconhecimento de direitos legítimos ou trocas bilaterais entre Administração e administrado quando estas se revelarem desejáveis ao interesse público primário. A sociedade tem interesse legítimo no atendimento a suas demandas com a celeridade, economia e qualidade que, em alguns casos, podem ser atingidas por meio de acordos. Transigir, em muitas hipóteses, não significa abrir mão do interesse público, mas atingi-lo de forma mais expedita (DALLARI, 2002, p. 24).

Sob a perspectiva da eficiência, a consensualidade é, também, em diversas situações, preferível. A Administração Pública tem um caráter instrumental, e desde a virada do século o ideal administrativo a que se aspira é o desapego ao formalismo estéril para a adoção de um modelo que olha menos para o procedimento e mais para os resultados. É preciso, nas precisas lições de Dallari (2002, p. 23), “superar concepções puramente burocráticas ou meramente formalísticas, dando-se maior ênfase ao exame da legitimidade, da economicidade e da razoabilidade, em benefício da eficiência”.

A transação é meio para a consecução de um fim pretendido pela Administração. Se esse fim puder ser atingido por uma via mais célere, menos traumática e menos desgastante que a via tradicional, o interesse público em sua dupla dimensão estará satisfeito.

Daí concluir-se que o consensualismo é compatível com a indisponibilidade do interesse público e com a eficiência administrativa, afinal, a transação, se bem

manejada, não é senão uma via expedida para a materialização do interesse público, ao proporcionar economia de tempo e recursos, além de viabilizar uma concertação de interesses legítimos, evitando os efeitos negativos que podem advir de uma solução adjudicada e unilateral.

5 Sobre a implementação da mediação no Tribunal de Contas da União: *fast-track* para a homologação de reequilíbrios em contratos de infraestrutura

O Direito está em constante evolução. Como Jhering gravou no tempo, “o direito não é uma simples ideia, mas uma força viva” (IHERING, 2006, p. 1), devendo mudar para acompanhar o estágio das relações sociais, e isso não poderia ser diferente no âmbito da Administração Pública. A mudança de orientação quanto à função administrativa deve ser acompanhada de equivalentes e necessárias adaptações nos seus meios e modos de controle.

Dentro do cenário de crescente pluralismo administrativo, um setor de ampla relevância é o da infraestrutura. As concessões são permeadas por uma pluralidade de interesses, convergindo, nelas, interesses do setor público, do setor privado e dos próprios usuários do serviço concedido, o que as faz um campo fértil para a implementação de fórmulas consensuais. Já é hora, porém, de tais fórmulas não se limitarem à mera elaboração das cláusulas contratuais, alcançando também a própria modelagem de um procedimento fiscalizatório que prestigie a cooperação em vez da unilateralidade, buscando-se inserir as instâncias controladoras no processo de confecção do contrato. A ideia é adquirir, com essa modelagem, mais segurança jurídica nas contratações públicas.

Sabe-se que há críticas quanto ao ritmo das agências reguladoras e do TCU na análise e no julgamento dos processos de concessão. Não nos deteremos sobre as razões dessa insatisfação. O que salta aos olhos, contudo, é que a as vicissitudes do procedimento legal têm há algum tempo gerado dificuldades para o gestor público na assinatura de aditivos de reequilíbrios econômico-financeiros nos contratos entre a Administração e suas concessionárias.

Isso se deve ao fato de que, atualmente, acaba sendo muito longo o lapso temporal entre o momento em que se exige do gestor uma tomada de decisão quanto ao contrato de concessão e aquele em que a agência ou a Corte de Contas chega a efetivamente auditar as cláusulas contratuais pactuadas. Não raro, quando da fiscalização, anos depois, são constatadas irregularidades e aplicadas as respectivas

sanções cabíveis. Desse cenário, inevitavelmente, decorre a insegurança que provoca o temor do gestor em agir.

Como temos sustentado, a hipertrofia do controle gera a infantilização da gestão pública, despertando nos gestores temor semelhante ao de crianças inseguras educadas por pais opressores. Em geral, agências reguladoras e gestores públicos têm evitado tomar decisões inovadoras por receio de seus atos serem questionados, tornando o processo moroso. Ou pior: deixam de decidir questões simples à espera de aval prévio do TCU⁵.

O que a experiência do TCU tem revelado é que se os reequilíbrios econômico-financeiros nos contratos de infraestrutura não forem homologados imediatamente, o contrato acaba se tornando um cadáver insepulto a assombrar dirigentes de agências e gestores públicos. Daí por que necessário um procedimento mais expedito para a homologação desses aditivos, o que vai ao encontro do pluralismo e da eficiência administrativa, além da segurança jurídica.

5.1 Desenho procedimental para a mediação no Tribunal de Contas da União

Considerando todo o aporte teórico até aqui exposto, bem como a já existência de autorização legal no art. 32, §5º, da Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação), que passou a admitir a mediação pelo Poder Público para “a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados pela administração com particulares”⁶, buscaremos, adiante, delinear um esquema procedimental que poderia ser adotado, *lege ferenda*⁷, para a implementação de uma câmara de mediação no âmbito do TCU destinada à rápida homologação de reequilíbrios nos projetos de infraestrutura.

O objetivo de uma câmara de mediação no TCU seria buscar encurtar a distância entre a pactuação e o controle, o hiato entre o gestor e o auditor, viabilizando um ajuste técnico e cooperativo na metodologia do contrato desde o seu início e a fixação de protocolos, procedimentos e critérios objetivos de uma maneira mais célere, o que já sinaliza a visão do Tribunal em uma costura contratual da qual se obtém segurança jurídica. A ideia vai ao encontro do art. 13, §1º, do Decreto nº 9.830/2019,

5 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/opiniao/o-risco-de-infantilizar-gestao-publica-22258401>. Acesso em: 14 jun. 2020.

6 Destaque-se, além disso, que autorização semelhante é também admitida pelo art. 11, inciso III, da Lei nº 11.079/2014 (Lei das parcerias público-privadas), assim como pelo art. 23-A da Lei nº 8.987/1995.

7 A expressão, registrada em latim, significa “lei a ser criada” (tradução nossa).

que regulamentou as recentes alterações feitas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) pela Lei nº 13.655/18, estabelecendo que “a atuação de órgãos de controle privilegiará ações de prevenção antes de processos sancionadores”.

O TCU tem se esforçado em realizar auditorias operacionais que identificam fragilidades, riscos e oportunidades de aperfeiçoamento na gestão governamental quanto à eficiência, e é comum que especialistas – como são os auditores – tenham concepções e fórmulas até mais inteligentes para eventuais problemas identificados. A proposta, com a mediação, evidentemente, não é substituir o gestor, mas aproximá-lo do auditor para, trabalhando juntos desde o início, chegarem às soluções mais eficientes e seguras.

Apesar do foco deste trabalho na utilização da mediação para a realização de reequilíbrios em contratos de concessão, a câmara, naturalmente, estaria habilitada a sediar transações em outros tipos de controvérsias entre o Poder Público e particulares.

A seguir, passamos a delinear o procedimento que reputamos adequado para a condução das negociações, que deverá envolver um esforço conjunto entre o Tribunal de Contas da União, a agência reguladora do respectivo setor, o poder concedente e os particulares envolvidos:

I) A mediação deverá ser iniciada exclusivamente por solicitação da agência reguladora ou do poder concedente dirigida ao Tribunal de Contas da União.

II) O mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito, tendo papel ativo na negociação do acordo e mantendo a interação com o relator e com as secretarias especializadas do Tribunal de Contas da União, com vistas a permitir que o acordo tenha tanto quanto possível aderência com parâmetros decisórios admitidos pelo tribunal.

III) Em caso de acordo, o mediador submeterá a minuta à deliberação do conselho diretor ou da diretoria colegiada da agência que, aprovando-a, remeterá à apreciação do Tribunal de Contas da União, que avaliará as concessões recíprocas sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e do interesse público em resolver o conflito sem judicialização e em prazo razoável.

IV) O Tribunal de Contas da União apreciará a proposta de acordo no prazo de trinta dias prorrogável uma única vez por igual período, sendo obrigatória a intervenção do Ministério Público junto ao TCU, que emitirá seu parecer no prazo de dez dias.

V) Aprovado total ou parcialmente o termo de acordo pelo plenário do Tribunal de Contas da União, a minuta do acordo retorna para a agência reguladora para homologação definitiva e produção de efeitos jurídicos.

VI) O termo homologado pela agência reguladora constituir-se-á em título executivo extrajudicial, só podendo ter seus pressupostos de fato e de direito desconstituídos em caso de dolo ou fraude.

Além disso, normas específicas deverão dispor acerca da organização e composição do Centro de Mediação na estrutura do Tribunal de Contas da União, assim como sobre os critérios de escolha e de responsabilidade dos mediadores, cujos requisitos de capacitação mínima, idoneidade pessoal e experiência profissional para inscrição no cadastro de mediadores poderão ser definidos por regulamento expedido pelo próprio TCU.

6 Conclusão

A mediação no setor público é fruto de um amplo redimensionamento da estrutura do Estado que apesar de ter, na seara administrativa, uma origem diversa daquela que incitou o mesmo movimento na seara jurisdicional, no fim, ambas concorrem para os mesmos objetivos: celeridade, segurança, pluralismo, eficiência e desjudicialização. A ideia de governança pública dos franceses foi responsável por lançar as primeiras sementes que décadas depois levariam ao florescimento da noção de consensualismo no Brasil.

A mediação na Administração Pública vem, mediante o concerto de interesses entre o setor público e privado, aproximando a Administração do administrado, incluindo-o de forma mais efetiva e cooperativa na própria densificação do interesse público, que não é monopólio do Estado. Já não se pode incorrer no equívoco de confundir interesse público com interesse da Administração e, pior, de vedar o avanço do consensualismo em virtude de uma leitura obsoleta acerca do princípio indisponibilidade do interesse público.

Como foi visto, a mediação é ferramenta adequada para concretizar a eficiência administrativa, seja porque cria uma via menos onerosa, mais célere e mais versátil para a composição do conflito ou para a administração dos interesses, seja porque concorre para a legitimação do processo decisório mediante a promoção do pluralismo administrativo, revelando-se, assim, imprescindível para dar concretude ao ideal de consensualismo.

Dentro desse cenário é oportuna a criação de um centro de mediação no TCU para a solução de controvérsias envolvendo a Administração Pública e o setor privado, sobretudo em questões envolvendo projetos de infraestrutura. Demonstrou-se que, em muitos casos, é imprescindível, para uma condução eficiente e justa da fiscalização, que o TCU avalie imediatamente as minutas dos contratos de concessão objeto de seu controle, participando desde o início na sua elaboração. Isso poderá ser feito mediante o procedimento de mediação, em uma atividade cooperativa que envolveria o TCU, a agência reguladora do respectivo setor, o poder concedente e os particulares interessados.

Conforme o modelo proposto, mediação deverá ser iniciada exclusivamente por solicitação da agência reguladora ou do poder concedente dirigida ao TCU. Havendo acordo, o mediador submeterá a minuta à deliberação do conselho diretor ou da diretoria colegiada da agência que, aprovando-a, remeterá à apreciação do TCU, que avaliará as concessões recíprocas sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e do interesse público em resolver o conflito sem judicialização e em prazo razoável. Aprovado total ou parcialmente o termo de acordo pelo plenário do TCU, a minuta do acordo retorna para a agência reguladora para homologação definitiva e produção de efeitos jurídicos.

O que se busca é fugir à lógica fiscalizatória punitiva viabilizando-se um ajuste técnico e cooperativo na metodologia do contrato mediante a fixação de protocolos, procedimentos e objetivos de uma maneira mais célere.

7 Referências

CADIET, Loic. Case management judiciaire et déformalisation de la procédure. **Revue Française D'Administration Publique**, n. 125, 2008/1, p. 133-150. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-133.htm>. Acesso em: 28 abr. 2020.

CAILLOSSE, Jacques. Les figures croisées du juriste et du manager dans la politique française de réforme de l'Etat. **Revue Française D'administration Publique**, n. 105-106, 2003/1, p. 123. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2003-1-page-121.htm#re23no23>. Acesso em: 28 abr. 2020.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. **Acesso à Justiça**. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988.

CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Capítulo I: Das normas fundamentais do Processo Civil (arts. 1º a 15). In: ALVIM, Teresa Arruda *et al.* (coord.). **Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

CASTELLS, Manuel. **A era da informação**: fim de milênio. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

CHEVALLIER, Jacques. La gouvernance, un nouveau paradigme étatique. **Revue Française D'administration Publique**, n. 105-106, 2003/1, p. 203-217. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2003-1-page-203.htm>. Acesso em: 29 abr. 2020.

CHEVALLIER, Jacques. **Le droit administratif entre science administrative et droit constitutionnel**. Curapp. Le droit administratif en mutation, Presses universitaires de France, 1993, p. 17. Disponível em: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01763594>. Acesso em: 30 abr. 2020.

DALLARI, Adilson de Abreu. Viabilidade da transação entre o Poder Público e o particular. **Revista Interesse Público**, n. 13, 2002.

DI SALVO, Sílvia Helena Picarelli Gonçalves Johonsom. **Mediação na Administração Pública Brasileira**: o desenho institucional e procedimental. São Paulo: Almedina Brasil, 2018.

GAJARDONI, Fernando da Fonseca. **Flexibilidade procedimental**: um novo enfoque para o estudo do procedimento em matéria processual. 2007. Tese (Doutorado em Direito Processual) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: doi:10.11606/T.2.2007.tde-06082008-152939. Acesso em: 12 mar. 2020.

GAUDIN, Jean-Pierre. **Gouverner par contrat**. Paris: Presses de Sciences Politiques. 2007.

IHERING, Rudolf von. **A luta pelo direito**. São Paulo: Forense, 2006, p. 1. Trad. João Vasconcelos.

MEDAUAR, Odete. **O Direito Administrativo em evolução**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A noção jurídica de "interesse público". *In*: **Grandes Temas de Direito Administrativo**. São Paulo: Malheiros, 2009.

OLIVEIRA, Gustavo Justino de; SCHWANKA, Cristiane. **A Administração consensual como a nova face da Administração Pública no século XXI**: fundamentos dogmáticos, formas de expressão e instrumentos de ação. *Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, ano 8, n. 32, 2008.

PERROT, Roger. O processo civil francês na véspera do século XXI. Trad. J.C. Barbosa Moreira. **Revista Forense**, v. 94, n. 342, p. 161-168, abr./jun. 1998.

VILLEY, Michel. **A formação do pensamento jurídico moderno**. Trad. Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

WATANABE, Kazuo. A mentalidade e os meios alternativos de solução de conflitos no Brasil. In: GRINOVER, A. P.; WATANABE, K.; LAGRASTA NETO, C. (coords.). **Mediação e gerenciamento do processo**. São Paulo: Atlas, 2008.

WEBER, Max. **Sociologia**. Coleção grandes cientistas sociais, n. 13. São Paulo: Ática, 1979.